

TAHKİME İLİŞKİN GÜNCEL EMSAL MAHKEME KARARLARI

AVUKAT HAKAN DİMDİK

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

I. TAHKİME ELVERİŞLİLİK

II. TAHKİM SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ

III. TAHKİM İRADESİNİN TAHKİM SÖZLEŞMESİNE AÇIKÇA TEREDDÜTE YER VERMEYECEK ŞEKİLDE YAZILMIŞ OLMASI GEREKİR

IV. TAHKİM SÖZLEŞMESİNİN BAĞIMSIZLIĞI

V. TAHKİM SÖZLEŞMESİ YAPABİLMEK İÇİN ÖZEL YETKİ GEREKİR

VI. TAHKİM İLK İTİRAZI

VII. İPTAL DAVASINDA İNCELEME YALNIZCA USULE İLİŞKİN YAPILIR

GİRİŞ

Tahkimde hızlı bir yargılama sürecinin olması ve özellikle iç tahkimde **hakem kararının doğrudan icra edilebilir olması** ticarî hayat için çok önemli avantajlardır. **Hakem kararları Devlet mahkemelerinin kararları gibi bağlayıcıdır** (3. HD 2025/4036 K.).

İstanbul Tahkim Merkezi tahkimin öngörüldüğü 5.000.000 TL değerindeki bir uyuşmazlıkta uyuşmazlık altı ayda çözümlenmekte iken bu değer altındaki uyuşmazlıklarda üç ayda çözümlenmektedir. Bununla birlikte uyuşmazlığın değerine bakılmaksızın seri tahkimde çözümleneceği de öngörülebilir. Yine değere bakılmaksızın seri tahkimin uygulanmayacağı da öngörülebilir.

Bununla birlikte kural olarak tahkim yargılaması gizlidir. Ticarî sırların gizliliğinin korunması işletmeler için oldukça önemli olup alenî olan mahkeme yargısının tercih edilmemesi için önemli bir sebeptir. ISTAC Kanunu'nun 14. Maddesine göre, merkez organları ve çalışanları bilgileri açıklayamaz. Bu gizlilik hakemler bakımından da geçerlidir.

Bu kadar hızlı ve gizli bir sürecin uyuşmazlık konusunda uzman hakemlerle yürütülmesi ve uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması ticarî hayatın hızı dolayısıyladır.

Ayrıca uluslararası arenada taraflar bilmedikleri ülke hukukuna göre yargılama yapılmasını istemedikleri için tahkim bu noktada da çare yaratmaktadır. Taraflar tahkim sözleşmesinde ya da şartında diledikleri ülke hukukuna ya da uluslararası sözleşmeye atıf yapabilirler. Hatta bunlardan ayrı olarak lex mercatoria'ya da sözleşmede atıf yapılabilmektedir.

ISTAC tahkim yargılamasında yargılama masrafları konusunda tarifeler bulunmakta olup tüm giderler önceden öngörülebilir niteliktedir.

İşte bu kadar avantajlı bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olan tahkim ile ilgili temel konuları içeren emsal mahkeme kararları derlenmesi tüm hukukçuların faydasınadır.

Avukat Hakan DİMDİK

I. TAHKİME ELVERİŞLİLİK

İstanbul BAM 14. HD 2022/1373 K.:

HMK'nın 412/1. maddesi uyarınca, "Tahkim sözleşmesi, tarafların, sözleşme veya sözleşme dışı bir hukuki ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tamamı veya bir kısmının çözümünün hakem veya hakem kuruluna bırakılması hususunda yaptıkları anlaşmadır". Bu yasal düzenlemede, ... Model Kanunu'ndaki tanım esas alınmıştır. Benzer bir tanım, Milletlerarası Tahkim Kanunu (MTK)'nın 4. maddesinde de yer almaktadır. Tahkim sözleşmesine dair yasal tanımdan da anlaşılacağı üzere, **tahkim sözleşmesinin konusu, tahkime elverişli her türlü hukuki uyuşmazlıklardır.** Uyuşmazlığın sözleşmeden, haksız fiilden, sebepsiz zenginleşmeden ya da kanundan doğmuş olmasının bir önemi yoktur. **Geçerli bir tahkim sözleşmesinin varlığından söz edebilmek için; tahkim sözleşmesinin yazılı şekilde yapılmış olması, tarafların tahkim iradesinin tahkim sözleşmesinde tereddüde yer vermeyecek derecede açık bir şekilde tecelli etmiş olması ve uyuşmazlık konusunun tahkime elverişli olması gerekir.** ... Sözleşmedeki tahkim şartında açıkça, şirketle ilgili olarak iki taraf arasında çıkacak uyuşmazlıkların hakemde çözüleceği kararlaştırılmış olup, şirketin yönetimi konusu, açıkça hissedarlar sözleşmesinin konusudur ve bu nedenle şirket müdürünün azli talebi, hissedarlar sözleşmesindeki tahkim koşulunun kapsamında kalmaktadır. Tahkim şartının mutlaka şirket ana sözleşmesinde yer alması gerekmez. Şirketin kuruluşundan önce taraflar arasında ortaklığın esasını düzenleyen bir hissedarlar sözleşmesi yapılması halinde, bu sözleşmeye de ortaklar arasında çıkacak uyuşmazlıkların, tahkim yoluyla çözülmesine ilişkin bir hüküm konabilir. Bu hükmün geçerli olması için, sonradan düzenlenecek şirket esas sözleşmesine de aynı hükmün eklenmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. ... tahkim sözleşmesinin konusu, tahkime elverişli her türlü hukuki uyuşmazlıklardır. Uyuşmazlığın sözleşmeden, haksız fiilden, sebepsiz zenginleşmeden ya da kanundan doğmuş olmasının bir önemi

yoktur. Hangi konuların tahkime elverişli olduđu HMK'nın 408. maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre, taşınmaz mallar üzerindeki ayni haklardan veya iki tarafın iradelerine tabi olmayan işlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar tahkime elverişli değildir. Bu hüküm, MTK'nın 1. maddesinin 4. fıkrasında, "Bu Kanun, Türkiye'de bulunan taşınmaz mallar üzerindeki aynî haklara ilişkin uyuşmazlıklar ile iki tarafın iradelerine tâbi olmayan uyuşmazlıklarda uygulanmaz" şeklinde tekrarlanmıştır. Bu yasal düzenlemelere ve öğretideki kabule göre, **tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri uyuşmazlıklar, tahkime elverişlidir** (KURU, Baki, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medenî Usul Hukuku, Legal Yayınevi, İstanbul, 2016, s.934). Özellikle tarafların üzerinde sulh olabilecekleri uyuşmazlıklar taraf iradesine tabi uyuşmazlıklardır (Hakan PEKCANITEZ/ Muhammet ÖZEKES/ Mine AKKAN/ Hülya TAŞ KORKMAZ, Pekcanitez Usul- Medeni Usul Hukuku, C:III, 15.Basım, İstanbul 2017, s.2632). Maddi hukuktaki tasarruf yetkisi, usul hukukunda tasarruf ilkesi olarak karşımıza çıkar. Tasarruf ilkesi, tarafların dava konusuna etki edebilmelerini ifade eder. Daha somut ifadesiyle; davanın ancak taraflarca açılacağı, davanın konusunun davacı tarafından belirleneceği, feragat, kabul ve sulh gibi işlemlerle dava konusu ve yargılama üzerinde tasarrufun mümkün olduğu, davanın geri alınabileceği gibi hususlar tasarruf ilkesinin görünümleridir. Tahkime elverişlilik, sözleşme özgürlüğünün sınırlarına tabidir. Bu konudaki özgürlüğün sınırları kanunla belirlenir. Bu sınırın belirlenmesinde tasarruf yetkisi önemli olmakla birlikte, kanun koyucu, tarafların tasarrufuna tabi olsa bile bazı konuları tahkime elverişli kılmayabilir (YEŞİLOVA, Bilgehan, Milletlerarası Ticari Tahkimde Nihai Karardan Önce Mahkemelerin Yardımı Ve Denetimi, İzmir, 2008, s. 318-321). Gerek HMK gerekse MTK, tahkime elverişli olmayan uyuşmazlık türlerini, "taşınmazın aynına ilişkin uyuşmazlıklar" ve "tarafların iradesine tabi olmayan uyuşmazlıklar" olarak sınırlandırmış, bunun dışındaki uyuşmazlıkların tahkime elverişli olduğunu benimsemiştir. Yani, **asıl olan tahkime elverişlilik olup, tahkime elverişsizlik istisnaidir**; tahkime başvurabilmek bir hak olduğuna göre,

bu hakkı sınırlandıran istisnaların dar yorumlanması gerekir. Bu bağlamda, şirket uyuşmazlıklarının da kural olarak tahkime elverişli olduğu öğretide kabul edilmektedir (İLHAN, Hüseyin Afşın, Tahkim Sözleşmesinin Geçerliliği, Ankara, 2016, s.240; AYOĞLU, s.79 ve s.162-169). Yargıtay da yukarıda anılan kararında belirtildiği üzere, hissedarlar sözleşmesindeki tahkim şartının geçerliliğini benimsemiş ve iptal davasının esasını incelemiştir (Yargıtay 11. HD'nin 2012/17087 E-2013/749 K sayılı, 15.01.2013 tarihli kararı). Yargıtay 11. HD'nin yukarıda anılan 2011/13485 E- 2012/19915 K sayılı, 05.12.2012 tarihli kararında, şirket esas sözleşmelerinde yer alan tahkim koşulunun geçersiz olduğunu ve bunun sonucu olarak şirket genel kurul kararının iptali davasının hakemde görülemeyeceğine hükmetmiş ise de bu karar, 6762 sayılı TTK (eTTK) yürürlükte iken ortaya çıkmış olan bir uyuşmazlığa ilişkindir. Nitekim, kanun koyucunun, şirket uyuşmazlıklarının tahkime elverişli olduğuna dair iradesini, 6102 sayılı TTK'nın 561. madde gerekçesinde açıkça dile getirdiği görülmektedir. Anılan madde şirket kurucuları, yöneticileri, denetçileri ve tasfiye memurları aleyhine açılacak sorumluluk davalarında yetkiyi düzenleyen bir madde olup, gerekçesinde, "6762 sayılı Kanunun 309. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü bağımsız bir hüküm haline getirilmiştir. İsviçre BK. m. 761'in aksine hüküm somut olaya göre yetkili olan mahkemeler yanına bir diğer yetkili mahkeme daha eklenmekte, yoksa inhisarî yetkiyi haiz bir mahkemeyi göstermemektedir. Tahkim ve yetki sözleşmesi yapmak yolu açıktır.". Gerekçe açıkça, şirket uyuşmazlıkları bakımından tahkim yolunun açık olduğunu ifade etmektedir. Şirket uyuşmazlıkları bakımından tahkim yolunun açılması ve esas sözleşmelere tahkim şartının konulabilmesi, yatırımların teşviki bakımından son derece önemlidir. Çünkü, günümüzde sermaye, tüm zamanlara göre daha fazla küreselleşmiştir. Uluslararası sermaye, kendisine en cazip kâr olanaklarını sunan ülkelere doğrudan veya dolaylı yatırımlar yapmaktadır. Uluslararası yatırım yapan sermayedarların yatırım yaptıkları yabancı ülke hukukuna ve yargı sistemine dair yeterli bilgiye sahip olmaması nedeniyle hukuki öngörülebilirlik ihtiyacı ortaya

çıkmiştir. Tahkim kurumu, bu ihtiyacın karşılanmasında önemli bir işlev üstlenmiştir. Tahkimin yatırımları teşvik eden bu özelliğini fark eden devletler, hukuk sistemlerini bu ihtiyaç doğrultusunda yeniden düzenleme çabasına girmişlerdir. Türk tahkim hukuku da bu çaba doğrultusunda, çağdaş tahkimin tüm uluslararası düzenlemelerini benimsemiş, bu bağlamda, uluslararası sözleşmelere taraf olmuş, HMK ve MTK'daki tahkim düzenlemeleri bakımından ... Model Kanununu esas almıştır (AKINCI, Ziya, Milletlerarası Tahkim, İstanbul, 2020, s.52; TUNÇ YÜCEL, Müjgan, HMK Uyarınca İhtiyati Tedbir ve Delil Tespiti, Ankara, 2013, s.68). Türk kanun koyucusunun tahkimi teşvik eden bu iradesinin, temel kanunların yorumlanmasında da dikkate alınması gerekir. Çağdaş hukuk sistemlerinin pek çoğunda, tahkimi destekleyen bir yorum tercih edilmektedir. Böylece mahkemelerin iş yükünün azaltılması ve yerli ve yabancı yatırımların teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Bunun sonucu olarak, tahkim itirazını inceleyen mahkemeler, tahkim sözleşmesini olabildiğince geniş yorumlayarak, tahkim sözleşmesinin geçerli olmasını sağlamaktadır (İLHAN, s.129). Bu bağlamda, bir konunun tahkime elverişli olup olmadığının belirlenmesinde, hukuk sisteminin izin verdiği ölçüde, tahkim anlaşmasına geçerlilik tanıyacak yorumun benimsenmesi gerekir. Somut olayda, tahkime konu uyuşmazlık, şirket yöneticisinin azline ilişkindir. Bu davada tasarruf ilkesi bütünüyle geçerlidir. Davacı davadan feragat edebileceği gibi davalıyla sulh olabilir, davalı davayı kabul ile bitirebilir. Davalı istifa etmek suretiyle de müdürlük görevini sona erdirebilir. Bu nedenle meselenin bütünüyle tarafların iradesine tabi olduğu açıktır. Şirkette davacı ve davalı dışında başka ortak da bulunmadığından, tahkim sözleşmesinin, sözleşmeye taraf olmayan kişilere sirayeti de söz konusu değildir. Yargıtayın yerleşik içtihadı uyarınca, şirket yöneticisinin azli davasında, şirket hasım (davalı konumunda) değildir. Uyuşmazlık tamamen tahkim sözleşmesinin tarafları arasında cereyan etmektedir. Uyuşmazlık, bütünüyle taraf iradelerine tabi olup tahkim koşulunun geçerli olduğunun, yani uyuşmazlığın tahkime elverişli olduğunun kabulü gerekir (AYOĞLU, s. 164). Yargıtayımızın şirket ortakları arasında uyuşmazlıkların tahkime

elverişliliği konusunda verdiği kararlar oldukça sınırlıdır. Yukarıda sözü edilen iki karardan başka; Yargıtay 11. HD'nin 2014/141 E- 2014/6951 K sayılı, 09.04.2014 tarihli kararında, hissedarlar sözleşmesindeki tahkim şartına dayanılarak şirketin fesih ve tasfiyesi için hakemde dava açılmayacağı, tahkim konusunda şirket ortakları arasındaki sözleşmede yer alan bir hükmün veya yapılacak hakem sözleşmesinin geçerli olmadığı, TTK'nın 530 ve 531. maddelerinde şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesini yetkili kılan hükümlerin buna izin vermeyeceği, tahkimin sadece taraf iradelerine tabi konularda mümkün olduğu, şirket ortakları arasındaki tahkim koşulunun geçerli olmadığı gerekçeleriyle, tahkim ilk itirazını kabul ederek davayı usulden reddeden ilk derece mahkemesi hükmünü bozmuştur. Öncelikle, mahkemede açılacak bir dava bakımından kesin yetki kuralının konulmuş olması, o meselenin tahkime elverişli olmadığına gerekçe yapılamaz (YEŞİLOVA, s.334-335; AYOĞLU, s.86-87).İkinci olarak, bu kararda yer alan "şirket ortakları arasındaki tahkim şartının geçerli olmadığına" dair genel gerekçenin hukuki dayanakları gösterilmemiştir. Şirket ortakları arasındaki tahkim şartının her uyuşmazlık bakımından geçerli olmayacağına dair bu genel tespit, yukarıda anılan madde 561 gerekçesine aykırı olduğu gibi, Yüce Daire, bu genel tespitinin dayanaklarını da açıklamamıştır. Anılan karar gerekçesinde tahkimin, yalnız tarafların arzularına tabi olan, yani davalı ile davacının mahkeme kararına gerek olmaksızın aralarında anlaşarak sonuçlandırabilecekleri uyuşmazlıklar konusunda geçerli olduğu belirtilmiş ise de bu gerekçe her zaman doğru olmayabilir. Çünkü, şirket ortakları anlaşıp bir genel kurul kararı alarak şirketin tasfiyesine karar verebilirler. Şirketin tasfiyesi her zaman mahkeme kararıyla olmaz. O halde fesih ve tasfiye davasının dahi tahkime elverişli olduğu savunulabilir. Ancak Yüce Dairenin, fesih ve tasfiye konusunun tahkime elverişli olmadığına dair vardığı sonuç, kamu düzeni gibi farklı mülahazalarla benimsenebilir. Nitekim öğretide fesih ve tasfiyenin şahsın hukukunu ilgilendirdiği, tüzel kişiliğin sona ermesi sonucunu doğurduğu, kamu düzeniyle ilgili yanlarının bulunduğu vb. gerekçelerle tahkime elverişli olmadığını savunan görüşler bulunduğu

gibi, aksini savunan görüşler de mevcuttur (Bu konuda Türk ve yabancı öğretide savunulan görüşler için bkz: AYOĞLU, s.138-147) Bununla birlikte, ortaklar arasındaki her türlü tahkim anlaşmasının geçersiz olduğuna dair genel bir gerekçenin benimsenmesi mümkün görünmemektedir. Örneğin, ortakların kâr payı dağıtımı konusunda ya da şirket yöneticisinin sorumluluğu konusunda ortaya çıkacak uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümleneceğine dair tüm ortakların anlaşma yapmaları mümkündür. Nitekim, TTK'nın 561. maddesinin gerekçesinde, sorumluluk davalarının tahkime elverişli olduğu açıkça benimsenmiştir. Bu bağlamda, somut olayda olduğu gibi, şirket ortakları, şirket yöneticisinin yönetim görevini esas sözleşme ve yasaya uygun yerine getirmediği iddiasıyla açılacak davaların hakemde görüleceğine dair anlaşma yapabilirler. Buna engel bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle, eldeki dava şirket yöneticisinin azline ilişkin olup TTK'nın 630/2. Maddesi gereğince, her ortak haklı sebeplerin varlığında yöneticilerin yönetim hakkının ve temsil yetkilerinin kaldırılmasını veya sınırlandırılmasını mahkemeden isteyebilir. Buradaki mahkeme kavramına, hakem de dahil kabul edilmelidir. Çünkü, şirket yönetiminden azil, ortaklar kurulu kararıyla her zaman mümkün olduğu gibi şirketin ortakları olan eldeki davanın taraflarının anlaşması ile her zaman şirket müdürünün temsil ve ilzam yetkisi kaldırılarak yerine yenisi görevlendirilebilir. Dava, davalının davayı kabul etmesiyle de sona erebilecek niteliktedir. Tüm bu nedenlerle, **şirket yöneticisinin azli davası bütünüyle tarafların iradesine tabi işlerden olup, bu tespitin doğal bir sonucu olarak da tahkime elverişli olduğu sonucuna varılmaktadır.** Hakem heyetinin azil konusundaki kararının ticaret sicil kaydında değişiklik yapmayı gerektirecek nitelikte olması da tek başına o işlemin tahkime elverişli olmaması sonucunu doğurmaz. MTK hükümlerine tâbi hakem kararlarının icrası zaten anılan Kanun'un 15/B maddesi uyarınca mahkemece verilecek "kararın icra edilebilir olduğuna dair belge" üzerine yapılacağından, sicil değişikliğinin mahkemenin bu icra edilebilirlik kararıyla yapılacağı dikkate alındığında, kararın sicil

değişikliği yapacak olmasının tahkime elverişliliği ortadan kaldırmayacağı tartışmasızdır. HMK hükümlerine tabi ulusal tahkimde ise hakem kararları ile mahkeme kararları eşit seviyeye getirilmiş ve mülga HUMK düzenlemesinden farklı olarak, hakem kararının icrası için mahkemeden icra edilebilirlik şerhi alınmasına gerek görülmemiştir. HMK'nın 443. maddesinin gerekçesinde, hakem kararının verildiği anda icra edilebilir hale geldiği, bu düzenlemenin tahkim kurumunu teşvik için getirildiği açıklanmıştır. Türk hukuk sistemi, ulusal tahkimde verilen hakem kararlarını mahkeme kararlarıyla eşit tuttuğuna göre, ticaret siciline tescil edilecek kararın mutlaka bir devlet mahkemesi tarafından verilmesi gerektiğini savunmak, kanun koyucunun iradesiyle uyuşan bir yaklaşım olmayacaktır (AYOĞLU, s.96-97). Kanun koyucu, bu konuda sadece tapu sicili bakımından bir tercih yapmış ve taşınmaz mallar üzerindeki aynı haklar yönünden tahkim yolunu kapatmış, şirket ilişkileri bakımından tahkime gitme imkânını kapatmamıştır. Nitekim, yöneticinin azline dair ticaret siciline yapılacak kayıt, kurucu nitelikte olmayıp açıklayıcı niteliktedir. Sicilde yapılacak değişiklik, şirketin azil sonrası geriye kalan diğer yöneticisinin sicile bildirimi üzerine yapılacaktır. Yöneticinin, hakem kararına dayanarak sicile yapacağı bu bildirimin, genel kurul kararıyla görevine son verilen yöneticinin görevinin sona erdiğinin sicile bildirilmesinden bir farkı yoktur. Bu nedenlerle de **salt sicil değişikliği gerektireceği gerekçesiyle meselenin tahkime elverişli olmadığı savunulamaz.** Taraflar arasında, Şirketle ilgili olarak çıkacak uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümleneceğine dair ifade, yeterince somuttur. Şirket ortaklığından kaynaklanacak uyuşmazlıklar tanımına, şirket yöneticisinin azli konusunun da dahil olduğundan kuşku duymamak gerekir. Nitekim, tahkim şartını havi hissedarlar sözleşmesinde, şirketin yönetiminin nasıl olacağı, iki ortağın münferit temsil yetkisini haiz olduğu belirtilmiş, şirketin yönetimine ve işleyişine dair düzenlemelere yer verilmiştir. O halde, aynı sözleşmede yer alan tahkim şartının, yöneticinin azli konusunu da kapsadığı açıktır.

İstanbul BAM 12. HD 2020/184 K.:

Gerek HMK, gerekse Milletlerarası Tahkim Kanunu tahkim yeri Türkiye bulunan uyuşmazlıklarda uygulanmaktadır. Geçerli bir tahkim şartı bulunup bulunmadığı hususunda Türkiye'nin taraf olduğu Newyork Sözleşmesi hükümlerine bakılmalıdır. Tarafların sözleşme veya sözleşme dışı bir hukuki ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tamamının veya bir kısmının çözümünü hakem veya hakem kuruluna bırakılması hususunda yaptıkları anlaşmalar tahkim sözleşmesi olarak adlandırılmakta olup yalnızca iki tarafın iradeleriyle tasarrufta bulunabilecekleri konularda tahkim sözleşmesi yapılabilir. İster bağımsız bir tahkim sözleşmesi şeklinde isterse bir tahkim şartı şeklinde yapılsın **tahkim sözleşmesinin geçerliliği için aranan temel unsurlar geçerli bir tahkim iradesinin varlığı ve yazılı şekil şartıdır.** Tahkim sözleşmesinin tabi olduğu şekil 1958 tarihli New York Sözleşmesi'nin 2. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre geçerli tahkim şartından bahsedebilmek için taraflarca imzalanmış yazılı bir anlaşma, karşılıklı mektup teatisi veya telgraf aranmaktadır. Sözleşme uyarınca davacı tarafından satın alınmış bulunan emtianın ayıplı olduğundan bahisle emtianın ayıp nedeniyle iadesi ve zararlarının tazmini talebinin belirli bir uyuşmazlığa ilişkin olması, özel hukuk uyuşmazlığı niteliğinde olması nedeniyle tahkim şartının geçerli bir tahkim şartı uyarınca uyuşmazlığın ICC tahkimde çözümü gerekmektedir.

II. TAHKİM SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ

Yargıtay HGK 2023/1348 K.:

Tahkim anlaşması yazılı şekilde yapılır. Yazılı şekil şartının yerine getirilmiş sayılması için, tahkim anlaşmasının taraflarca imzalanmış yazılı bir belgeye veya taraflar arasında teati edilen mektup, telgraf, teleks, faks gibi bir iletişim aracına veya elektronik ortama geçirilmiş olması ya da dava dilekçesinde yazılı bir tahkim anlaşmasının varlığının iddia edilmesine davalının verdiği cevap dilekçesinde itiraz edilmemiş olması gerekir. Asıl sözleşmenin bir parçası haline getirilmek amacıyla tahkim şartı içeren bir belgeye yollama yapılması halinde de geçerli bir tahkim anlaşması yapılmış sayılır.

İstanbul BAM 14. HD 2022/1373 K.:

HMK'nın 412/1. maddesi uyarınca, "Tahkim sözleşmesi, tarafların, sözleşme veya sözleşme dışı bir hukuki ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tamamı veya bir kısmının çözümünün hakem veya hakem kuruluna bırakılması hususunda yaptıkları anlaşmadır". Bu yasal düzenlemede, ... Model Kanunu'ndaki tanım esas alınmıştır. Benzer bir tanım, Milletlerarası Tahkim Kanunu (MTK)'nın 4. maddesinde de yer almaktadır. Tahkim sözleşmesine dair yasal tanımdan da anlaşılacağı üzere, tahkim sözleşmesinin konusu, tahkime elverişli her türlü hukuki uyuşmazlıklardır. Uyuşmazlığın sözleşmeden, haksız fiilden, sebepsiz zenginleşmeden ya da kanundan doğmuş olmasının bir önemi yoktur. **Geçerli bir tahkim sözleşmesinin varlığından söz edebilmek için; tahkim sözleşmesinin yazılı şekilde yapılmış olması, tarafların tahkim iradesinin tahkim sözleşmesinde tereddüde yer vermeyecek derecede açık bir şekilde tecelli etmiş olması ve uyuşmazlık konusunun tahkime elverişli olması gerekir.** ... Bu açıklamalara göre, taraflar arasında, eldeki davaya konu uyuşmazlığı kapsayan yazılı bir tahkim sözleşmesinin bulunduğu ve geçerlilik bakımından yazılılık koşulunun sağlandığı belirlenmiştir.

İstanbul BAM 45. HD 2021/398 K.:

İster bağımsız bir tahkim sözleşmesi şeklinde isterse bir tahkim şartı şeklinde yapılsın **tahkim sözleşmesinin geçerliliği için aranan temel unsurlar geçerli bir tahkim iradesinin varlığı ve yazılı şekil şartıdır.** Tahkim sözleşmesinin tabi olduğu şekil doğrudan doğruya Türkiye'nin tabi olduğu 1958 tarihli New York Sözleşmesi'nin 2. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre tahkim şartından bahsedebilmek için taraflarca imzalanmış yazılı bir anlaşma, karşılıklı mektup teatisi veya telgraf aranmaktadır. Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun 4. maddesinde ise; "Yazılı şekil şartının yerine getirilmiş sayılması için tahkim anlaşmasının taraflarca imzalanmış bir belgeye veya taraflar arasında teati edilen mektup, telgraf, teleks, faks gibi iletişim aracına veya elektronik ortama geçirilmiş olması ya da dava dilekçesinde yazılı bir tahkim antlaşmasının varlığının iddia edilmesine davalının verdiği cevap dilekçesinde itiraz edilmemiş olması gerekir. Asıl sözleşmenin bir parçası haline getirilmek amacıyla tahkim şartı içeren bir belgeye yollama yapılması halinde de geçerli bir tahkim anlaşması yapılmış sayılır" hükümlerine yer verilmiştir. Nitekim 6100 sayılı HMK'nın 412. maddesinde New York Sözleşmesi ve Milletlerarası Tahkim Kanunu hükümlerine eşdeğer nitelikte düzenlemelere yer verilmiştir. (Yargıtay 11/05/2015 tarih 2015/1687 Esas 2015/6696).

İstanbul BAM 12. HD 2020/184 K.:

Gerek HMK, gerekse Milletlerarası Tahkim Kanunu tahkim yeri Türkiye bulunan uyuşmazlıklarda uygulanmaktadır. Geçerli bir tahkim şartı bulunup bulunmadığı hususunda Türkiye'nin taraf olduğu Newyork Sözleşmesi hükümlerine bakılmalıdır. Tarafların sözleşme veya sözleşme dışı bir hukuki ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tamamının veya bir kısmının çözümünü hakem veya hakem kuruluna bırakılması hususunda yaptıkları anlaşmalar tahkim sözleşmesi olarak adlandırılmakta olup yalnızca iki tarafın iradeleriyle tasarrufta bulunabilecekleri konularda tahkim sözleşmesi yapılabilir. İster bağımsız bir tahkim sözleşmesi şeklinde isterse bir tahkim şartı şeklinde yapılsın

tahkim sözleşmesinin geçerliliği için aranan temel unsurlar geçerli bir tahkim iradesinin varlığı ve yazılı şekil şartıdır. Tahkim sözleşmesinin tabi olduğu şekil 1958 tarihli New York Sözleşmesi'nin 2. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre geçerli tahkim şartından bahsedebilmek için taraflarca imzalanmış yazılı bir anlaşma, karşılıklı mektup teatisi veya telgraf aranmaktadır. Sözleşme uyarınca davacı tarafından satın alınmış bulunan emtianın ayıplı olduğundan bahisle emtianın ayıp nedeniyle iadesi ve zararlarının tazmini talebinin belirli bir uyuşmazlığa ilişkin olması, özel hukuk uyuşmazlığı niteliğinde olması nedeniyle tahkim şartının geçerli bir tahkim şartı uyarınca uyuşmazlığın ICC tahkimde çözümü gerekmektedir.

III. TAHKİM İRADESİNİN TAHKİM SÖZLEŞMESİNE AÇIKÇA TEREDDÜTE YER VERMEYECEK ŞEKİLDE YAZILMIŞ OLMASI GEREKİR

Yargıtay 3. HD 2026/129 K.:

Taraflar arasında düzenlenen 01.03.2022 tarihli sözleşmede; "Taraflar arasında akdedilen bu avukatlık sözleşmesinden ve vekâlet ücretinden kaynaklanan uyuşmazlıklar öncelikle, arabuluculuk girişimiyle çözümlenecektir. Arabuluculuk masraflarına taraflar eşit olarak katlanacaktır. Arabuluculuk girişiminden sonuç alınamazsa, uyuşmazlık Baro Hakem Kurulunca çözümlenecektir. Türkiye Barolar Birliği Hakem Yönetmeliği bu sözleşmenin bir parçasıdır." şeklinde olup, taraflar bu avukatlık sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkta öncelikle arabuluculuk yoluna başvurmuş, sonuç alınamayınca Tahkime başvurmuşlardır. Sözleşmenin ilgili hükmünde **uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözümlenememesi hâlinde tahkim yoluyla çözüleceğine dair taraf iradeleri herhangi bir tereddüde yer vermeyecek şekilde açık olarak belirtilmiştir**. Bunun yanında tahkime konu uyuşmazlık, avukatlık sözleşmesinden kaynaklandığı halde davalı avukatın davacıya vekaleten yerine getirmeyi üstlendiği avukatlık hizmeti tüketici işlemi niteliğinde olmadığından tahkime elverişli olduğundan geçerlidir.

İstanbul BAM 14. HD 2022/1373 K.:

HMK'nın 412/1. maddesi uyarınca, "Tahkim sözleşmesi, tarafların, sözleşme veya sözleşme dışı bir hukuki ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tamamı veya bir kısmının çözümünün hakem veya hakem kuruluna bırakılması hususunda yaptıkları anlaşmadır". Bu yasal düzenlemede, ... Model Kanunu'ndaki tanım esas alınmıştır. Benzer bir tanım, Milletlerarası Tahkim Kanunu (MTK)'nun 4.

maddesinde de yer almaktadır.Tahkim sözleşmesine dair yasal tanımdan da anlaşılacağı üzere, tahkim sözleşmesinin konusu, tahkime elverişli her türlü hukuki uyuşmazlıklardır. Uyuşmazlığın sözleşmeden, haksız fiilden, sebepsiz zenginleşmeden ya da kanundan doğmuş olmasının bir önemi yoktur. Geçerli bir tahkim sözleşmesinin varlığından söz edebilmek için; tahkim sözleşmesinin yazılı şekilde yapılmış olması, tarafların tahkim iradesinin tahkim sözleşmesinde tereddüde yer vermeyecek derecede açık bir şekilde tecelli etmiş olması ve uyuşmazlık konusunun tahkime elverişli olması gerekir. ... Tahkim sözleşmesinde, tarafların, hakeme başvurmadan önce arabulucuya başvurmalarını ya da uzlaşma görüşmeleri yapmalarını veya hakem bilirkişiye başvurmalarını zorunlu kılan ve ancak bu yollardan sonuç alınamazsa hakeme dava açılabileceğini öngören tahkim sözleşmeleri geçerlidir. Çünkü, esas olan tarafların uzlaşarak uyuşmazlığı sonlandırmalarıdır. Bu nedenle, hakemde dava açılmadan önce tarafların uzlaşma çabası içerisine gireceklerine ve bu amaçla, öncelikle arabulucuya başvurmaları gerektiğine dair **tahkim öncesi ihtiyari veya zorunlu aşamalar öngören sözleşme hükümleri (tahkim öncesi uyuşmazlık çözüm klozları), tarafların uyuşmazlığı hakeme götürme iradelerini sakatlamaz** (Bu konuda ayrıntılı açıklamalar için bknz: EKŞİ, Nuray, Tahkim Öncesi Uyuşmazlık Çözüm Usulleri ve Bu Usuller Tüketilmeden Tahkime Başvurulmasının Sonuçları, İstanbul, 2015). Somut olayda taraflar, bu sözleşmeyle ve şirketle ilgili olarak ortaya çıkacak uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözülmemesi halinde tahkim yoluyla çözüleceğine dair açık ve kesin iradelerini ortaya koymuşlardır. Tahkim sözleşmesi, bu bakımdan da geçerlidir.

İstanbul BAM 13. HD 2021/884 K.:

Dava, taraflar arasında imzalanan tek satıcılık sözleşmesinin davalı tarafça feshedilmesi nedenine dayalı olarak denkleştirme bedeli, rücu tazminat ve yedek parça stokunun geri alınması talebine ilişkin alacak davasıdır.Mahkemece, davalı tarafından ilk itiraz olarak ileri sürülen, Uyuşmazlığın Tahkim Yolu İle Çözülmesine Dair itirazın kabulü ile, 6100

sayılı HMK'nın 116/1-b maddesi gereğince ayrıca taraflar arasındaki sözleşmenin 11/K maddesi uyarınca davacının davasının usulden reddine karar verilmiş ve karara karşı davacı vekili tarafından istinaf başvurusunda bulunulmuştur. Dava konusu olayda, Davacı taleplerini taraflar arasında 25.06.1985 tarihinde imzalanan distribütörlük sözleşmesine dayanarak öne sürmektedir.Somut uyuşmazlık; Taraflar arasında 25.06.1985 tarihinde imzalanan sözleşmenin davalı tarafından feshedilmesinden kaynaklanmaktadır. MÖHUK 47. Madde hükmüne göre yer itibariyle yetkinin münhasır yetki esasına göre tayin edilmediği hallerde, taraflar arasında yabancılık unsuru taşıyan ve borç ilişkisinden doğan uyuşmazlığın yabancı bir devlet mahkemesinde görülmesi konusunda anlaşmaları mümkündür. Yetki şartı taraflar arasındaki ilişkiyi düzenleyen sözleşmeye ayrı bir madde olarak konabileceği gibi ayrı bir sözleşme olarak da düzenlenebileceği, dava konusu uyuşmazlığın yabancı unsur taşıması, mahkemenin yetkisinin münhasır yetki esasına göre düzenlenmemiş olması, uyuşmazlığın akdi borç ilişkisinden doğması gerekir. Taraflar arasında 25.06.1985 tarihli tek satıcılık sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmenin 3.1 maddesinde; Anlaşmanın 25 Haziran 1985 tarihinde yürürlüğe gireceği ve taraflardan herhangi biri altı ay önceden yazılı bildirimle feshetmedikçe yürürlükte kalacağı düzenlenmiştir.Davalı tarafından çekilen 21/08/2012 tarihli fesih yazısı ile sözleşmenin 20/08/2014 tarihinde sona ereceği davacıya bildirilmiştir. 25.06.1985 tarihli sözleşmenin TAHKİM başlıklı K maddesinde tahkim şartı düzenlenmiştir. Sözleşmenin K-i maddesinde;" ... ve Distribütör, iş bu anlaşma ile ilgili olarak aralarındaki her türlü anlaşmazlığı görüşme yoluyla ya da başka bir şekilde dostane biçimde çözmek üzere daima çaba gösterecektir, " düzenlemesi yer almaktadır. Sözleşmenin K-ii maddesinde; "Bu şekilde çözümlenemeyen her türlü ihtilaf, bu kapsamda İngiltere Uluslararası Ticaret Odası Ulusal Komitesi olan Başkanın kurallarına uygun olarak tayin edilen bir yada birkaç hakem tarafından Uluslararası Ticaret Odası kuralları kapsamında kesin olarak çözümlenecektir. Tahkim Londra'da yapılacaktır.(L) geçerli hukuk, (i) işbu anlaşma, tüm hususta İngiliz Hukukuna tabi olacak ve bu hukuka uygun

tefsir edilecektir, (ü) Jaguar ve Distribütör İngiliz Mahkemelerinin gayri münhasır yetkilerini kabul ederler," hükmü düzenlenmiştir. HMK'nın 116. maddesinde tahkim itirazı ilk itirazlar arasında sayılmış olup davalı vekilince süresinde tahkim ilk itirazında bulunulmuştur. Tahkim itirazında bulunulması üzerine, mahkemece tahkim anlaşmasının bulunup, bulunmadığı araştırılırken, söz konusu tahkim anlaşmasının geçerli olup olmadığının da incelenmesidir. MTK'nun 5.maddesinde "tahkim itirazının kabulü halinde, mahkeme davayı usulden reddeder" hükmüne yer verilmiştir. O halde mahkemenin görevi burada sadece hukuki durumu ne olursa olsun bir tahkim şartının var olup olmadığını incelemekle sınırlı değil fakat geçerli bir tahkim anlaşmasının var olup olmadığını incelemektir. Zira kanunda "kabul edilebilir" bir tahkim anlaşmasının bulunması şartı aranmaktadır. Davaya konu uyuşmazlığın sözleşmeye göre açık ve net bir şekilde tahkim koşuluna bağitlandığı, sözleşmedeki ... ve Distribütör İngiliz Mahkemelerinin gayri münhasır yetkilerini kabul ederler düzenlemesinin tahkime ilişkin usul hükümlerinde İngiliz Mahkemelerinin yetkili olduğunun anlaşılması gerektiğinden, tahkim şartını ortadan kaldırmayacağından davacı vekilinin tahkim şartının mutlak, kesin bir yol olarak düzenlenmediğine yönelik istinaf sebebi yerinde görülmemiştir. Sözleşmenin tarafı ... Limited'in unvanı, ... Limited olarak değiştiği, sonrasında, ... grubunun iç yapısındaki değişiklik nedeniyle, ... Limited ihracat işini ana şirketi olan ...Şirketi'ne devrettiği dosya kapsamından tesbit edilmiştir.Bu kapsamda, Davacı ve ...'in, 25 Şubat 2013 tarihinde yazılı bir yenileme sözleşmesi akdettiği, söz konusu sözleşme ile ... Limited, Bayilik Sözleşmesi'nden doğan tüm hak, borç ve yükümlülüklerini olduğu gibi ...'e devrettiği ve önceki sözleşmenin tarafı ... Limited'in değiştiğine dair sözleşme olup 25.06.1985 tarihli sözleşme maddelerinin değiştirilmediği aynen devam ettiğinden 25.06.1985 tarihli sözleşmedeki tahkim şartı da geçerli olup davacı vekilinin tahkim şartının geçerli olmadığına yönelik istinaf sebebi yerinde görülmemiştir.

İstanbul BAM 45. HD 2021/398 K.:

Davalı, temlik eden ile davalı arasında düzenlenen sözleşmeden dolayı uyuşmazlıklara ABD California eyaleti hukukunun uygulanması gerektiğini belirterek tahkim ilk itirazında bulunmuştur. Dosya kapsamına göre; dava dışı Şirketi ile davalı arasında 27/03/2019 tarihli Master "SaaS" Agreement adlı sözleşme imzalandığı ve davacının dava dışı şirketinden alacağını temlik aldığı, dava dışı Velocity Inc. şirketi ile davalı arasında imzalanan temliknameye konu sözleşmenin 9. maddesinde; "Her bir tarafın davacının bulunduğu ülkenin hukukunu uygulama ve mahkemelerine başvurma hakkı saklı olmak üzere, kanunlar ihtilafı kuralları uygulanmayacak şekilde işbu Sözleşme'ye her bakımdan hakim hukuk Kalifornia Eyaleti hukukudur. İşbu Sözleşme'den ya da işbu Sözleşme'ye ya da konusuna ilişkin olarak ortaya çıkan tüm uyuşmazlıklar münhasıran Amerikan Tahkim Birliğinin Ticari Tahkim Kuralları uyarınca bağlayıcı tahkim yolu ile çözülecektir." hükümlerinin bulunduğu görülmüştür. 6100 sayılı HMK'nın 116. maddesinde; "(1) İlk itirazlar aşağıdakilerden ibarettir: a) Kesin yetki kuralının bulunmadığı hâllerde yetki itirazı. b) Uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülmesi gerektiği itirazı. c) İş bölümü itirazı. 117. maddesinde; "(1) İlk itirazların hepsi cevap dilekçesinde ileri sürülmek zorundadır; aksi hâlde dinlenemez. (2) İlk itirazlar, dava şartlarından sonra incelenir. (3) İlk itirazlar, ön sorunlar gibi incelenir ve karara bağlanır." hükümleri yer almaktadır. Tarafların sözleşme veya sözleşme dışı bir hukuki ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tamamının veya bir kısmının çözümünü hakem veya hakem kuruluna bırakılması hususunda yaptıkları anlaşmalar tahkim sözleşmesi olarak adlandırılmakta olup yalnızca iki tarafın iradeleriyle tasarrufta bulunabilecekleri konularda tahkim sözleşmesi yapılabilir. İster bağımsız bir tahkim sözleşmesi şeklinde isterse bir tahkim şartı şeklinde yapılsın tahkim sözleşmesinin geçerliliği için aranan temel unsurlar geçerli bir tahkim iradesinin varlığı ve yazılı şekli şartıdır. Tahkim sözleşmesinin tabi olduğu şekil doğrudan doğruya Türkiye'nin tabi olduğu 1958 tarihli New York Sözleşmesi'nin 2. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre tahkim şartından bahsedebilmek için taraflarca imzalanmış yazılı bir anlaşma, karşılıklı mektup teatisi

veya telgraf aranmaktadır. Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun 4. maddesinde ise; "Yazılı şekil şartının yerine getirilmiş sayılması için tahkim anlaşmasının taraflarca imzalanmış bir belgeye veya taraflar arasında teati edilen mektup, telgraf, teleks, faks gibi iletişim aracına veya elektronik ortama geçirilmiş olması ya da dava dilekçesinde yazılı bir tahkim antlaşmasının varlığının iddia edilmesine davalının verdiği cevap dilekçesinde itiraz edilmemiş olması gerekir. Asıl sözleşmenin bir parçası haline getirilmek amacıyla tahkim şartı içeren bir belgeye yollama yapılması halinde de geçerli bir tahkim anlaşması yapılmış sayılır" hükümlerine yer verilmiştir. Nitekim 6100 sayılı HMK'nın 412. maddesinde New York Sözleşmesi ve Milletlerarası Tahkim Kanunu hükümlerine eşdeğer nitelikte düzenlemelere yer verilmiştir. (Yargıtay 11/05/2015 tarih 2015/1687 Esas 2015/6696)Belirtilen yasal düzenlemeler ve açıklamalar doğrultusunda somut olay değerlendirildiğinde; davaya konu sözleşmenin 9. maddesinde, mevcut sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar için tahkim yolunun yanı sıra, davacının bulunduğu ülkenin hukukunu uygulama ve mahkemelerine başvurma imkanı da getirdiği görülmektedir. Kural olarak tahkim yargısı istisnai nitelikte olup, tarafların bu husustaki iradelerini açık ve kesin bir şekilde bildirmiş olmaları gerekir. Başka bir ifadeyle, tahkim sözleşmesi veya şartının, uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözümlenmesi yolundaki taraf iradesini tereddüde yol açmayacak şekilde içermesi gerekmektedir. Nitekim bu husus Yargıtay 'nin 2016/4735 Esas 2017/259 Karar sayılı ilamında "...Tahkim şartı veya anlaşmasının geçerli olabilmesi için yanların tahkim iradesini açıkladıkları tahkim şartı ya da sözleşmede tartışma ve karışıklığa neden olmayacak biçimde açık ve kesin olarak belirtmiş olmaları zorunludur. Dairemiz ve yerleşik Yargıtay içtihatlarında geçerli bir tahkim şartı varlığı veya tahkim anlaşmasının geçerli sayılabilmesi için uyuşmazlığın kesin olarak hakemde çözüleceğinin kararlaştırmış olması gerektiği kesin iradeyi ortadan kaldıran ya da zayıflatan kayıtların tahkim sözleşmesi veya şartını geçersiz-hükümsüz kılacağı kabul edilmektedir." şeklinde ifade edilmektedir. O halde davaya konu sözleşmenin 9. Maddesinde

düzenlenen tahkim şartı mutlak ve kesin bir uyuşmazlık çözüm yolu olmaktan çıktığı, geçersiz olduğu kabulü gerekir.

İstanbul BAM 15. HD 2019/15 K.:

Yargıtay Yüksek 15. Hukuk Dairesi kararlarında da belirtildiği üzere, kural olarak, hukuki uyuşmazlıkların çözüm yeri mahkemelerdir. Ancak, sözleşmenin tarafları kamu düzenini ilgilendirmeyen ve arzularına bağlı olan konularda aralarında çıkacak uyuşmazlıkların halli için tahkim yolunu seçebilirler. Uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözümlenebilmesi için taraflar arasında geçerli olarak yapılmış bir tahkim anlaşmasının varlığı zorunludur. Tahkim anlaşması, bağımsız bir tahkim sözleşmesi şeklinde yapılabileceği gibi asıl sözleşmeye tahkim şartı konulmak suretiyle de yapılabilir. Tahkim anlaşmasının kurucu unsuru, uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümlenmesine ilişkin irade açıklamasıdır. **Tahkim anlaşmasının geçerli olabilmesi için tarafların tahkim iradelerinin şüpheye ve karışıklığa yer vermeyecek şekilde açık ve kesin olması gerekir.** Uyuşmazlıkların öncelikli olarak hakemlerce, olmazsa mahkemelerce çözüme bağlanacağı kararlaştırılan tahkim sözleşmeleri veya şartları açık ve kesin tahkim iradesini içermediğinden **geçerli sayılamaz.**

IV. TAHKİM SÖZLEŞMESİNİN BAĞIMSIZLIĞI

Sakarya BAM 2022/1700 K.:

Tahkim sözleşmesi ya da asıl sözleşme içerisinde yer alsa dahi tahkim şartı asıl sözleşmeden bağımsız, ondan ayrı bir anlaşmadır. Bunun sonucu olarak tahkim şartının geçerliliği, esas sözleşmenin geçerliliğine bağlı değildir. **Asıl sözleşmenin geçersiz olması tahkim sözleşmesi veya şartının geçerliliğini etkilemeyeceği gibi, tahkim anlaşmasının herhangi bir sebeple geçersiz olması asıl sözleşmeyi etkilemez ve onu geçersiz kılmaz** (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 22.02.2012 gün 2011/11-742 Esas, 2012/82 Karar sayılı ilamı). Bunun sonucu olarak asıl sözleşmenin geçerli olması, sayılması ya da geçersizliğini ileri sürmenin hakkın kötüye kullanılması niteliğinde sayılması, ondan bağımsız olan tahkim anlaşması ya da şartının geçerli olması, sayılması ve geçersizliğini ileri sürmenin hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğunun kabulünü gerektirmez (Yargıtay 15. HD., 05.11.2020 tarih, 2019/3156 E., 2020/2913 K.). Bu nedenle, istinaf incelemesi sözleşmenin 22. maddesinin geçerli olup olmadığı yönünden yapılmış olup, sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğine dair bir istinaf incelemesi yapılmamıştır.

İstanbul BAM 14. HD 2022/1373 K.:

Sözleşmedeki tahkim şartında açıkça, şirketle ilgili olarak iki taraf arasında çıkacak uyuşmazlıkların hakemde çözüleceği kararlaştırılmış olup, şirketin yönetimi konusu, açıkça hissedarlar sözleşmesinin konusudur ve bu nedenle şirket müdürünün azli talebi, hissedarlar sözleşmesindeki tahkim koşulunun kapsamında kalmaktadır. Tahkim şartının mutlaka şirket ana sözleşmesinde yer alması gerekmez. Şirketin kuruluşundan önce taraflar arasında ortaklığın esasını düzenleyen bir hissedarlar sözleşmesi yapılması halinde, bu sözleşmeye de ortaklar arasında çıkacak uyuşmazlıkların, tahkim yoluyla çözülmesine ilişkin bir hüküm konabilir. Bu hükmün geçerli olması için, sonradan düzenlenecek

şirket esas sözleşmesine de aynı hükmün eklenmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. ... Bu açıklamalara göre, taraflar arasında, eldeki davaya konu uyuşmazlığı kapsayan yazılı bir tahkim sözleşmesinin bulunduğu ve geçerlilik bakımından yazılılık koşulunun sağlandığı belirlenmiştir. Bu nedenlerle, davacı vekilinin, tahkim koşulunun şirket esas sözleşmesinde yer almaması nedeniyle geçersiz olduğuna dair istinaf nedeni yerinde görülmemiştir.

Sakarya BAM 7. HD 2022/557 K.:

Uyuşmazlık, taraflar arasında geçerli bir tahkim sözleşmesi (ya da tahkim şartı) olup olmadığı ve davada tahkim mercinin yetkili ve görevli olup olmadığıdır.

Davalı şirketlerin tahkim itirazlarında dayandıkları "Agreement Between IFF Aroma Esans Sanayi ve Ticaret A.Ş. and Bulutoglu Doğal Katkı Malzemeleri ve Tarım Ürünleri Ltd. Şti." isimli sözleşmenin dilinin İngilizce olduğu, Türkçe nüshasının bulunmadığı, sözleşmeyi davacı adına B...'nın imzaladığı ve tahkimin sözleşmenin 22. maddesinde düzenlendiği anlaşılmıştır.

Tahkim sözleşmesi ya da asıl sözleşme içerisinde yer alsa dahi tahkim şartı asıl sözleşmeden bağımsız, ondan ayrı bir anlaşmadır. Bunun sonucu olarak tahkim şartının geçerliliği, esas sözleşmenin geçerliliğine bağlı değildir. Asıl sözleşmenin geçersiz olması tahkim sözleşmesi veya şartının geçerliliğini etkilemeyeceği gibi, tahkim anlaşmasının herhangi bir sebeple geçersiz olması asıl sözleşmeyi etkilemez ve onu geçersiz kılmaz (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 22.02.2012 gün 2011/11-742 Esas, 2012/82 Karar sayılı ilamı). Bunun sonucu olarak asıl sözleşmenin geçerli olması, sayılması ya da geçersizliğini ileri sürmenin hakkın kötüye kullanılması niteliğinde sayılması, ondan bağımsız olan tahkim anlaşması ya da şartının geçerli olması, sayılması ve geçersizliğini ileri sürmenin hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğunun kabulünü gerektirmez (Yargıtay 15. HD., 05.11.2020 tarih, 2019/3156 E., 2020/2913 K.) Bu nedenle, istinaf incelemesi sözleşmenin 22. maddesinin geçerli

olup olmadığı yönünden yapılmış olup, sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğine dair bir istinaf incelemesi yapılmamıştır.

İstanbul BAM 15. HD 2019/16 K.:

Tahkim sözleşmesi asıl sözleşmeden bağımsız ve ayrı bir anlaşma niteliğindedir. Bu durum asıl sözleşme içerisinde düzenlenen tahkim klozları için de geçerlidir. Tahkim klozunun geçersizliği asıl sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyeceği gibi, asıl sözleşmenin geçersizliği de tahkim anlaşmasının geçerliliğini etkilemez.

V. TAHKİM SÖZLEŞMESİ YAPABİLMEK İÇİN ÖZEL YETKİ GEREKİR

İstanbul BAM 15. HD 2019/16 K.:

Tahkim sözleşmesi asıl sözleşmeden bağımsız ve ayrı bir anlaşma niteliğindedir. Bu durum asıl sözleşme içerisinde düzenlenen tahkim klozları için de geçerlidir. Tahkim klotunun geçersizliği asıl sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyeceği gibi, asıl sözleşmenin geçersizliği de tahkim anlaşmasının geçerliliğini etkilemez. **TBK'nın 504. Maddesine göre vekilin tahkim sözleşmesi yapabilmesi için kendisine özel yetki verilmesi gerekmektedir.** Aksi halde müvekkili adına yapılan tahkim sözleşmesi hukuken geçersizdir. Aynı husus temsilci için de geçerlidir. Temsilci, tahkim yetkisi ile yetkilendirilmediği sürece tahkim anlaşması yapamaz. **Özel yetkisi bulunmayan temsilcinin yaptığı tahkim sözleşmesi, temsil edilen tarafından icazet verilmedikçe hüküm doğurmaz.**

Somut olayda, davacı ortak girişimi oluşturan şirketlerden STFA İnşaat AŞ çalışanı ve proje müdürü olarak kendisine bir nevi temsil görevi verilmiş olan M. E. Ö.'a tahkim sözleşmesi yapmak üzere özel yetki verilmediği, yapılan tahkim sözleşmesine sonradan icazet verilmediği anlaşıldığından, tahkim sözleşmesinin geçersiz olduğu sonucuna varılmaktadır. İTOTAM Tahkim Divanı tarafından bu yöndeki itirazın reddine karar verilmesi ve tahkim yargılamasına devamla esas hakkında karar verilmesi doğru olmayıp, bu durum aynı zamanda kamu düzenine de aykırı olduğundan, hakem kararının MTK'nın 15/A-1-a ve 15/A-2-b maddeleri gereğince iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

VI. TAHKİM İLK İTİRAZI

Sakarya BAM 2022/1700 K.:

Uyuşmazlık, taraflar arasında geçerli bir tahkim sözleşmesi (ya da tahkim şartı) olup olmadığı ve davada tahkim mercinin yetkili ve görevli olup olmadığıdır.

Davalı tarafın tahkim ilk itirazında bulunduğu anlaşılmakla; 6100 sayılı HMK'nın 117. maddesi gereğince öncelikle ilk itirazlar değerlendirilmiştir.

Mahkemece, tahkim ilk itirazının kabulü ile davanın dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine karar verilmiş, karara karşı davacılar vekili istinaf kanun yoluna başvurmuştur.

İstanbul BAM 12. HD 2020/184 K.:

HMK'nın 116. maddesinde tahkim itirazı ilk itirazlar arasında sayılmış olup davalı vekilince süresinde uzatılmış cevap süresi içerisinde tahkim ilk itirazında bulunulmuştur.

Ankara BAM 22. HD 2017/978 K.:

4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 4. Maddesinde “-Tahkim anlaşması, tarafların, sözleşmeden kaynaklansın veya kaynaklanmasın aralarında mevcut bir hukukî ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tümünün veya bazılarının tahkim yoluyla çözülmesi konusunda yaptıkları anlaşmadır. Tahkim anlaşması, asıl sözleşmeye konan tahkim şartı veya ayrı bir sözleşme ile yapılabilir.

Tahkim anlaşması yazılı şekilde yapılır. Yazılı şekil şartının yerine getirilmiş sayılması için, tahkim anlaşmasının taraflarca imzalanmış yazılı bir belgeye veya taraflar arasında teati edilen mektup, telgraf, teleks, faks gibi bir iletişim aracına veya elektronik ortama geçirilmiş olması ya da dava dilekçesinde yazılı bir tahkim anlaşmasının varlığının

iddia edilmesine davalının verdiği cevap dilekçesinde itiraz edilmemiş olması gerekir. Asıl sözleşmenin bir parçası hâline getirilmek amacıyla tahkim şartı içeren bir belgeye yollama yapılması hâlinde de geçerli bir tahkim anlaşması yapılmış sayılır.

Tahkim anlaşması, tarafların tahkim anlaşmasına uygulanmak üzere seçtiği hukuka veya böyle bir hukuk seçimi yoksa Türk hukukuna uygun olduğu takdirde geçerlidir.

Tahkim anlaşmasına karşı, asıl sözleşmenin geçerli olmadığı veya tahkim anlaşmasının henüz doğmamış olan bir uyuşmazlığa ilişkin olduğu itirazında bulunulamaz.” Şeklinde düzenlenmiştir.

Aynı kanunun 5. Maddesinde – Tahkim anlaşmasının konusunu oluşturan bir uyuşmazlıkta dava mahkemede açılmışsa; karşı taraf, tahkim itirazında bulunabilir. Tahkim itirazının ileri sürülmesi ve tahkim anlaşmasının geçerliliğine ilişkin uyuşmazlıkların çözülmesi, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun ilk itirazlara ilişkin hükümlerine tâbidir. **Tahkim itirazının kabulü halinde, mahkeme davayı usulden reddeder.** Yine 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim kanunun 7/H. Maddesinde “ **Hakem veya hakem kurulu, tahkim anlaşmasının mevcut veya geçerli olup olmadığına ilişkin itirazlar da dahil olmak üzere, kendi yetkisi hakkında karar verebilir.** Bu karar verilirken, bir sözleşmede yer alan tahkim şartı, sözleşmenin diğer hükümlerinden bağımsız olarak değerlendirilir. Hakem veya hakem kurulunun asıl sözleşmenin hükümsüzlüğüne karar vermesi, kendiliğinden tahkim anlaşmasının hükümsüzlüğü sonucunu doğurmaz.” Denilmiştir

Dosya kapsamına göre davalının HMK ' nun 117. maddesi gereğince yasal süresi içerisinde sözleşmede belirtilen tahkim şartı uyarınca tahkim itirazında bulunduğu, taraflar arasında tanzim edilen sözleşmenin 8. maddesinde, anlaşmazlıkların 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu hükümlerine göre çözümleneceğinin belirtildiği, tahkim sözleşmesinin sözleşmede yer alan diğer hükümlerden bağımsız olarak değerlendirilmesi gerektiği, tahkim sözleşmesinin tarafları bağlayacağı

nitelikte bulunduđu, davalının da HMK' nun 116-1-b ve 117. maddeleri gereğince süresinde ve usulüne uygun olarak tahkim itirazında bulunduđu mahkemece verilen tahkim itirazının kabulü ile 4686 sayılı yasanın 5/1 maddesi uyarınca davanın usulden reddine dair verilen kararında usul ve esas yönünden yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davacı vekilinin istinaf başvurusunun HMK.nun 3531-b1 maddesi gereğince esastan reddine karar vermek gerekmiştir.

VII. İPTAL DAVASINDA İNCELEME YALNIZCA USULE İLİŞKİN YAPILIP ESASA İLİŞKİN İNCELEME YAPILAMAZ

Yargıtay 3. HD 2026/1561 K.:

Hakem kararının iptali sebepleri, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 439/2 maddesinde sınırlı olarak belirtilmiş olmakla davacı tarafından ileri sürülen iptal sebeplerinin dava konusu tahkim kararına konu uyuşmazlıkta bulunmadığı gibi tahkim şartının yer aldığı Avukatlık sözleşmesine göre ifaya konu olan Avukatlık hizmetinin tüketici işlemi niteliğinde de olmadığından tahkime elverişli olduğu kararın pozitif hukuk kurallarına göre isabetli olup olmadığı hususunun ise inceleme kapsamı dışında kaldığının anlaşılmasına göre, davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun bulunan kararın onanmasına karar verilmiştir.

Yargıtay 3. HD 2023/3067:

Tahkim dosyasının incelenmesinde; Hakemlerin taraflara tahkim yargılaması süresince eşit olarak iddia ve savunmalarını ve itirazlarını ileri sürme imkanı tanıdığı, Bölge Adliye Mahkemesi kararında da belirtildiği üzere tahkim yargılamasının yasada öngörülen usul kurallarına uygun olarak yürütüldüğü, ispat yükümlülüğüne ilişkin maddi ve usul hukuku kurallarına göre değerlendirme yapılarak karar verilmiş olduğu, uygulanacak hukuk kurallarının tespiti ve yorumunun hakeme ait olduğu, **iptal davasında hakem kararının yerinde olup olmadığı veya hukukun doğru uygulanıp uygulanmadığı hususlarının değerlendirilemeyeceği** dikkate alındığında, davacı vekilinin bu yöne ilişkin temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.

Yargıtay HGK 2023/1348 K.:

İptal davasında ise, hakem kararının tarafların ileri sürdüğü maddi vakıalara uygunluğu, hukukun doğru uygulanıp uygulanmadığına bakılamayacaktır. Sınırlı olarak belirlenen iptal nedenlerinin kararda bulunup bulunmadığına bakılacak, **maddi hukukun uygulanmasına ilişkin olarak esas denetimi yapılmayacaktır.** İptal davasında esas denetimi yapılamamasının doğal sonucu olarak da verilen kararın hukuka uygun olup olmadığı denetlenemeyecektir (Ağırman, s. 646).

Ankara BAM 27. HD 2019/4 K.:

Hakem kararının iptali sebepleri, 6100 Sayılı HMK'nın 439/2 maddesinde 9 bent halinde tahdidi olarak sayılmıştır. Bu maddeye göre;

- a) Tahkim sözleşmesinin taraflarından birinin ehliyetsiz ya da tahkim sözleşmesinin geçersiz olduğu,
- b) Hakem veya hakem kurulunun seçiminde, sözleşmede belirlenen veya bu Kısımda öngörülen usule uyulmadığı,
- c) Kararın, tahkim süresi içinde verilmediği,
- ç) Hakem veya hakem kurulunun, hukuka aykırı olarak yetkili veya yetkisiz olduğuna karar verdiği,
- d) Hakem veya hakem kurulunun, tahkim sözleşmesi dışında kalan bir konuda karar verdiği veya talebin tamamı hakkında karar vermediği ya da yetkisini aştığı,
- e) Tahkim yargılamasının, usul açısından sözleşmede veya bu yönde bir sözleşme bulunmaması hâlinde, bu Kısımda yer alan hükümlere uygun olarak yürütülmediği ve bu durumun kararın esasına etkili olduğu,
- f) Tarafların eşitliği ilkesi ve hukuki dinlenilme hakkına riayet edilmediği,
- g) Hakem veya hakem kurulu kararına konu uyuşmazlığın Türk hukukuna göre tahkime elverişli olmadığı,

ğ) Kararın kamu düzenine aykırı olduğu tespit edilirse, hakem kararları iptal edilebilir.

Yukarıda açıklanan kanun maddesi ve somut olay birlikte değerlendirildiğinde; Hakem kararına konu uyuşmazlığın Türk Hukukuna göre tahkime elverişli olduğu, uyuşmazlığın taraflar arasındaki sözleşmenin 46. maddesinde belirtilen tahkim şartı kapsamında bulunduğu, tahkime konu taleplerin tümünün değerlendirilerek karara bağlandığı, kararın kamu düzenine aykırı olmadığı, kararın esasına etkili usul hatası yapılmadığı ve özellikle tahkim süresinin son olarak Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 19/12/2016 tarih ve 2016/545 Esas-2016/355 Karar sayılı kararı ile 29/12/2016 tarihinden itibaren 2 ay süre ile uzatılmış olup, kararın da uzatılan bu süre içinde verildiği, tahkim yargılamasında yüklenici MESA tarafından verilen 11/02/2015 ve 10/07/2015 tarihli dilekçelerin hakem heyeti tarafından HMK'nın 428/3 maddesi kapsamında kabul edilmesinin usule aykırı bulunmadığı, 10/02/2015 tarihli bilirkişi kurulu raporunun hakem heyetince geçersiz sayılmasının tarafların eşitliği ve hukuki dinlenme hakkının ihlali niteliğinde olmadığı anlaşılmış, Hakem kararının iptali hususunda ileri sürülen diğer iptal nedenlerinin ise, hakem kararının esasına ilişkin olması nedeniyle HMK'nın 439/2 maddesinde yer alan, sınırlı iptal nedenlerine bağlı kalınarak inceleme yapılması gerekliliği karşısında yerinde görülmemiş, davanın reddine karar verilmesi gerekmektedir.